

계속 고용 기대권

－ 5가지 기대권 법리－

강 선 희*

목 차

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| I. 들어가는 글 | IV. 계속 고용 거절의 합리적
이유 |
| II. 계속 고용 기대권 개념과
종류 및 유형 | V. 맺는 글 |
| III. 기대권의 인정기준과 판단요소 | |

I. 들어가는 글

지난 2023년 6월 대법원은 정년 후 재고용 기대권¹⁾과 정규직 전환 채용 기대권²⁾을 잇달아 내놓으면서 5가지의 기대권 법리를 탄생시켰다. 이러한 기대권 법리는 기간제근로자의 계약기간 만료 등과 같은 고용종료를 보호하기 위해 탄생하였는데, 그 출발점은 사실상 무기계약 법리라 볼 수 있다. 사실상 무기계약 법리는 1994년³⁾ 처음 등장한 이래 2006년⁴⁾에 정식화되었는데, 근로계약 당사자가 계약기간을 정한

DOI:<https://doi.org/10.46329/LLF.2024.03.41.133>

논문투고일자: 2024.02.28., 심사일자: 2024.03.11., 게재확정일자: 2023.03.12.

* 고려대학교 노동·일반대학원 강사, 법학박사

1) 대법원 2023. 6. 29. 선고 2018두62492 판결. 이 판결에 앞서 정년 후 재고용 기대권을 인정하는 판결(대법원 2023. 6. 1. 선고 2018다275925 판결)이 나왔으나 판시 사항에 재고용 거절의 법적 효과에 대한 설시내용이 누락되어 위 판결을 기본 판결로 본다.

2) 대법원 2023. 6. 15. 선고 2021두39034 판결

3) 대법원 1994. 1. 11. 선고 93다17843 판결

근로계약을 체결하였으나 장기간 반복 갱신하거나 당사자의 진정한 의사 등을 종합적으로 고려할 때 기간의 정함이 형식에 불과한 경우 사실상 기간의 정함이 없는 근로계약으로 보아 사용자의 갱신 거절에 해고제한 법리를 유추 적용하는 것이다. 즉 근로자 입장에서 보면 기간을 정한 근로계약은 형식에 불과하기 때문에 기간 만료에도 불구하고 ‘계속 고용의 기대’를 가진다고 볼 수 있다.⁵⁾

이와 같은 계속 고용에 대한 기대는 기간의 정함이 형식에 불과한 경우뿐만 아니라 일정한 요건을 충족할 경우 기간제 근로계약이 갱신되거나 정규직으로 전환된다는 규정이나 신뢰 등을 통해서도 형성될 수 있다. 갱신기대권은 2005년⁶⁾에 등장한 이래 2011년 서울특별시시설관리공단 사건의 판결(대법원 2011. 4. 14. 선고 2007두1729 판결)을 통해 판례 법리로 정립되었고, 무기계약직(정규직) 전환 기대권(대법원 2016. 11. 10. 선고 2014두45765 판결)으로 그 외연이 확대되었다. 또한 사용자가 변경되더라도 고용승계 관행 등이 있다면 새로운 사용자계승계되어 계속 고용될 것이라는 기대가 형성될 수 있다(고용승계 기대권).⁷⁾ 이에 더하여 앞서 언급한 정년 후에도 일정한 요건을 충족할 경우 기간제로 재고용될 수 있다는 정년 후 재고용 기대권, 자회사 설립을 통해 위탁업무를 처리하는 경우 자회사가 종전 용역업체 소속 근로자를 정규직으로 채용하여 새로운 근로관계가 성립될 것이라는 정규직 전환 채용 기대권을 통해서도 계속 고용의 기대가 형성될 수 있다. 이러한 측면에서 근로계약의 갱신 또는 정규직으로의 전환이나 고용승계 등으로 근로관계가 계속될 것이라는 기대권이라는 의미에서 이를 통칭하여 ‘계속 고용 기대권’으로 표현한다.

앞서 언급한 사실상 무기계약 법리도 ‘기대권 법리’로 포섭할 수 있

4) 대법원 2006. 2. 24. 선고 2005두5673 판결

5) 대법원 2007. 9. 7. 선고 2005두16901 판결 등

6) 대법원 2005. 7. 8. 선고 2002두8640 판결

7) 대법원 2021. 4. 29. 선고 2016두57045 판결

을 것이나 이 글에서는 판례가 명시적으로 ‘기대권’으로 명명한 5가지 유형의 기대권에 한정하여 살펴본다. 먼저 기대권의 개념과 종류 및 유형을 살펴본다(Ⅱ). 또한 기대권의 인정기준과 판단기준을 기대권 유형별 판단구도의 차이에 따라 판단요소의 기능, 인정기준의 단위, 기대권 형성을 부인할 만한 ‘특별한 사정’으로 나누어 검토본다(Ⅲ). 그리고 계속 고용 거절의 합리적 이유에 대해 일반적 내용을 검토한 후 이를 유형화해 유형에 따른 합리적 이유의 판단기준을 검토한다(Ⅳ).

Ⅱ. 계속 고용 기대권 개념과 종류 및 유형

1. 기대권의 개념

민법에서의 기대권(期待權, Anwartschaftsrecht, expectant right)은 권리가 발생하기 위한 요건 중 일부만을 갖추었을 뿐 남은 요건이 갖추어지면 장차 권리를 취득할 수 있는 경우 현재의 그러한 기대상태를 권리로서 보호하는 것을 말한다. 이를 희망권(希望權)이라고 부르기도 하며, 조건부 권리(민법 제148조, 제149조)와 기한부 권리(민법 제154조) 등이 이에 속한다.⁸⁾ 민법 제148조과 제149조는 법률행위의 효력 발생을 장래의 불확실한 사실의 성취 여부에 의존케하는 조건이 붙은 법률행위가 있다면 그 법률행위의 당사자는 장차 조건이 성취됨에 따라 일정한 이익을 얻을 것이라는 기대를 갖게 되므로 이를 보호하기 위한 규정이다. 즉 ‘조건의 성부가 미정한 동안 조건의 성취로 인하여 생길 상대방의 이익을 해하지 못’하고, ‘조건의 성취가 미정한 권리의무는 일반 규정에 의하여 처분·상속·보존 또는 담보로 할 수 있’다고 규정한 것이다. 권리를 취득하지 않으나 조건의 성취로 권리를 취득할 수 있을 것이라는 기대상태를 권리로서 보호하는 것이다. 권리

8) 지원림, 「민법강의」 제9판, 홍문사, 2011, 40면.

의 취득상태라는 측면에서 보면 ‘기대권’은 이미 획득한 권리를 의미하는 ‘기득권’과 대비되는 개념으로 볼 수 있다. 이러한 이유로 기득권을 침해하는 것은 특별한 사정이 없는 한 인정되지 않으나 기대권은 그 보호의 정도가 기득권에 미치지 못한다.

한편 계속 고용 기대권의 경우 일정한 요건이 충족되면 근로계약이 갱신(정규직으로 전환 내지 재고용)된다는 규정이 있거나 그와 같은 신뢰관계가 형성되어 있다면 근로자에게는 그에 따라 근로계약이 갱신(정규직 전환 내지 재고용)될 수 있으리라는 정당한 기대권이 인정되고, 사용자에게 근로계약을 갱신(정규직 전환 내지 재고용)할 의무가 있으므로 합리적 이유없이 이를 침해하는 것은 부당해고와 마찬가지로 효력이 없다(갱신기대권, 정규직 전환 기대권, 정년 후 재고용 기대권). 또한 용역업체의 변경이나 자회사 설립을 통해 위탁업무를 처리하는 경우 새로운 용역업체 또는 자회사가 종전 용역업체 소속 근로자에 대한 고용을 승계하거나 정규직으로 채용하여 새로운 근로관계가 성립될 것이라는 신뢰관계가 형성되어 있다면 근로자에게는 그에 따라 고용이 승계되거나 정규직 전환되어 채용될 수 있으리라는 정당한 기대권이 인정되고, 사용자에게 고용을 승계하거나 정규직으로 채용할 의무가 있으므로 합리적 이유없이 이를 침해하는 것은 부당해고와 마찬가지로 효력이 없다(고용승계기대권, 정규직 전환 채용 기대권). 이렇듯 판례가 표현하는 계속 고용에 대한 ‘기대권’은 근로자 입장에 파악된 개념으로 일정한 요건을 충족하면 근로계약을 갱신하거나 재고용하는 등의 계속 고용에 대해 약정이 있거나 그와 같은 신뢰관계가 형성되어 있다면 근로자로서는 계속 고용될 것이라는 ‘기대권’이 형성된다는 것이다. 이를 사용자 입장에서 표현하면 ‘의무’, 즉 갱신할 의무, 승계할 의무, 재고용할 의무 등이 될 것이다.⁹⁾

9) 강선희, “기간제근로자의 고용종료를 보호하기 위한 판례 법리”, 「노동법학」 제87호, 한국노동법학회, 2023, 261면 각주6) 참조

요컨대 이 양자의 기대권은 기대상태를 권리로서 보호한다는 측면에서만 같다고 볼 수 있다. 민법 제148조 등의 기대권은 권리발생요건을 모두 갖추지 못하여 현재 권리를 취득하지 않았으나 일부 남은 요건을 갖추면 권리를 취득할 수 있을 것이라는 기대상태를 권리로서 보호하는 것이다. 한편 계속 고용 기대권은 규정이나 관행 등으로 계속 고용에 대한 신뢰관계가 형성되어 있는 경우 이를 거부할 만한 합리적 이유가 없다면 고용이 계속될 수 있을 것이라는 기대상태를 권리로서 보호하는 것이다. 민법 제148조의 기대권에서의 ‘조건의 성부’는 계속 고용 기대권에서의 ‘합리적 이유의 유무’에 견줄 수 있을 것이다.

2. 계속 고용 기대권의 종류 및 유형

(1) 계속 고용 기대권의 종류

첫째, 근로계약 갱신기대권(대법원 2011. 4. 14. 선고 2007두1729 판결, 이하 ‘기대권① 판결’이라 한다)과 무기계약직(정규직) 전환 기대권(대법원 2016. 11. 10. 선고 2014두45765 판결, 이하 ‘기대권② 판결’이라 한다)은 근로계약기간 만료에도 일정한 요건이 충족되면 근로계약이 갱신되거나 정규직으로 전환된다는 규정이 있거나 그와 같은 신뢰관계가 형성되어 있다면 근로자는 그에 따라 근로계약이 갱신 또는 정규직으로 전환될 수 있으리라는 기대권을 가진다는 것이다.

둘째, 정년 후 재고용 기대권(대법원 2023. 6. 29. 선고 2018두62492 판결, 이하 ‘기대권③ 판결’이라 한다)은 정년에 도달하였음에도 일정한 요건이 충족되면 기간제로 재고용된다는 규정이 있거나 그와 같은 신뢰관계가 형성되어 있다면 특별한 사정이 없는 한 근로자는 그에 따라 정년 후 재고용되리라는 기대권을 가진다는 것이다.

셋째, 고용승계기대권(대법원 2021. 4. 29. 선고 2016두57045 판결, 이하 ‘기대권④ 판결’이라 한다)은 용역업체의 변경에도 새로운 용역

업체가 종전 용역업체 소속 근로자의 고용을 승계하여 새로운 근로관계가 성립될 것이라는 신뢰관계가 형성되었다면 특별한 사정이 없는 한 근로자는 그에 따라 새로운 용역업체로 고용이 승계되리라는 기대권을 가진다는 것이다. 기대권④ 판결은 용역업체의 변경이 있는 경우였으나 도급업체가 기존에 직접 처리하던 업무를 위임이나 도급의 형식으로 외부업체에게 맡겨 수행하도록 하는 외주화(outsourcing)의 경우에도 이 판결의 기본 틀을 원용할 수 있을 것이다.¹⁰⁾

고용승계기대권은 용역업체 등 아웃소싱업체의 변경이 사업양도(사업이전) 법리로 포섭할 수 없는 한계로 탄생한 판례 법리라 할 수 있으므로 아웃소싱업체의 변경은 ‘사업양도’에 해당(법률요건)하지 않을 뿐만 아니라 법률효과도 다르다.¹¹⁾ 사업양도가 이루어진 경우 원칙적으로 해당 근로자들의 근로관계가 양수하는 기업에 포괄적으로 승계되므로¹²⁾ 종전 근로계약상의 지위도 그대로 유지되고¹³⁾, 종전 취업규칙 등에 의해 규율되던 임금·근로시간 등 근로조건도 그대로 유지된다.¹⁴⁾ 사업양도로 인한 승계의무는 고용만을 승계하는 것이 아니

10) 다만 세부적인 인정기준 및 판단요소는 용역업체의 변경과 다르게 보아야 한다. 외주화(outsourcing)하는 경우 도급업체와 용역업체 간의 고용을 승계하기로 하는 규정 또는 약정은 기대권④에서의 고용승계약정과 성격이 다르기 때문이다. 외주화(outsourcing)하는 도급업체는 승계 대상이 되는 근로자에 대하여 사용자 지위에 있기 때문이다. 따라서 종전 사용자(도급업체)와 새로운 사용자(용역업체) 간에 근로자의 고용승계에 대한 약정이 있다면 ‘특별한 사정’이나 ‘다른 판단요소’에 대한 고려 없이 이러한 고용승계약정만으로 그대로 고용승계의무를 부담한다고 보아야 한다. 그리고 이 경우의 법적 효과는 ‘전적’ 또는 사업양도 시의 고용승계와 동일하게 판단해야 한다.

11) 기업이 기존에 직접 처리하던 업무를 외주화하거나, 외주주었던 업무를 직접 처리하는 직영 시 및 외주업체를 변경하는 것은, 기업변동의 한 유형으로써 사업 자체의 양도를 통해 ‘사업주체’가 변경되는 것이 아니라 사업주체는 변경 없이 그대로 존속하면서 위임이나 도급 등을 통해 해당 업무의 ‘관리주체’가 변경되는 것에 불과하기 때문에 법리상 ‘사업양도’로 보기 어려운 측면이 있다. 강선희, “위탁 등 아웃소싱과 노동법적 쟁점-기간제근로자를 중심으로-”, 「노동법포럼」 제38호, 노동법이론실무학회, 2023, 171~173면 참조

12) 대법원 2001. 7. 27. 선고 99두2680 판결 등

13) 대법원 2001. 11. 13. 선고 2000다18608 판결

라 종전 근로계약상의 지위(근로자·사용자의 지위) 자체가 이전하는 것이므로 ‘근로관계의 승계’이다. 반면 기대권이 인정되어 새로운 사용자가 부담하는 승계의무는 ‘고용’승계의무에 한정된다. 고용승계기대권 법리는 아웃소싱업체의 변경 등으로 인한 고용종료는 원칙적으로 해고는 아니나 고용이 승계되어 근로관계가 계속될 것이라는 신뢰관계가 형성되어 있음에도 사용자가 일방적으로 승계를 거부하는 것은 근로자에게 해고와 마찬가지로의 효과가 나타나기 때문에 해고제한 법리(근로기준법 제23조제1항과 제28조)를 유추적용하는 판례 법리이다.¹⁵⁾ 이러한 이유로 고용승계기대권의 효과는 용역업체가 변경되더라도 고용종료 없이 새로운 사용자에게 고용이 승계되어 계속되는 것에 그치고 사업양도와 같이 근로관계 자체가 승계되는 것은 아니다.

넷째, 정규직 전환 채용 기대권(대법원 2023. 6. 15. 선고 2021두39034 판결, 이하 ‘기대권⑤ 판결’이라 한다)은 도급업체가 용역업체에 위탁하여 수행하던 업무를 자회사의 설립을 통하여 이에 위탁하는 경우 용역업체 소속 근로자를 정규직으로 채용하여 새롭게 근로관계가 성립될 것이라는 신뢰관계가 형성되었다면 특별한 사정이 없는 한 근로자는 자회사의 정규직으로 전환 채용될 수 있으리라는 기대권을 가진다는 내용이다. 이는 주로 2017. 7. 20. 발표된 정부의 ‘공공부문 비정규직 근로자 정규직 전환 가이드라인’에 따라 이루어진 것으로 실무에서의 확장성은 그리 커 보이지 않으나 직영 시 원용될 수 있을 것으로 보인다. 즉 도급업체가 외부업체에게 맡겨 수행하도록 했던 업무를 직접 처리하는 직영(insourcing)의 경우에도 적용될 수 있는데, 도급업체가 직접 고용하거나 자회사의 설립을 통해 고용하는 것은 본질적으로 다르지 않기 때문이다.¹⁶⁾

14) 대법원 1997. 12. 26. 선고 97다17575 판결 등

15) 이에 대한 자세한 내용은 강선희, “기간제근로자의 고용종료를 보호하기 위한 판례 법리”, 262~267면 참조

16) 강선희, “기간제근로자의 고용종료를 보호하기 위한 판례 법리”, 296면.

(2) 유형

위 5가지 기대권을 사용자의 변경 여부에 따라 구분하면, 동일한 사용자를 대상으로 하는 기대권은 기대권①, ②, ③(이하 ‘기대권A그룹’이라 한다)이고, 새로운 사용자를 대상으로 하는 기대권은 기대권④, ⑤(이하 ‘기대권B그룹’이라 한다)이다. 사용자의 변경 여부에 따라 기대권의 인정기준과 판단요소뿐만 아니라 판단의 구도도 달라질 수 밖에 없다. 아래에서 각 기대권의 인정기준과 판단요소를 살펴볼 때 이 분류 방식에 따라 서술한다.

한편 기대권의 주체인 근로자의 고용형태에 따라 구분하면, 기대권①, ② 및 ④는 기간제근로자의 고용종료와, 기대권③은 정규직근로자의 정년 후 기간제근로자로의 재고용 여부와, 기대권④는 간접고용 근로자의 직접고용과 관련되어 있다. 애초의 기대권이 기간제근로자의 고용종료로부터 근로관계를 보호하기 위해 해고제한법리를 유추 적용하는 것으로 출발했던 사실을 고려하면 정년 후 재고용 기대권(기대권③)은 다른 기대권에 비해 보호필요성 측면에서 상대적으로 낮다고 볼 수 있다.

Ⅲ. 기대권의 인정기준과 판단요소

1. 판단구도의 차이에 따른 판단요소의 기능

기대권 인정의 판단구도에 따라 판단요소의 기능이 달라질 수 있다.¹⁷⁾ 동일한 사용자를 대상으로 하는 기대권A그룹의 경우 ‘근로계약 당사자 사이에 일정한 요건이 충족되면’ 근로계약이 갱신되거나 정규직으로 전환되거나 기간제로 재고용된다는 취지의 규정 즉 명시적 규

17) 판단의 구도에 대한 자세한 내용은 강선희, “기간제근로자의 고용종료를 보호하기 위한 판례 법리”, 291면 이하 참조

정(A-1)이 있거나, 이와 같은 규정이 없더라도(A-1이 없더라도) 제반 사정을 통해 근로관계가 계속될 것이라는 신뢰관계(A-2)가 형성되어 있다면 기대권이 인정되는 구조이다.

반면 기대권B그룹의 기대권④는 ‘새로운 용역업체가 종전 용역업체 소속 근로자에 대한 고용을 승계하기로 하는 조항을 포함하고 있는지 여부를 포함한 구체적인 계약내용’ 등의 해당 근로관계 및 용역계약을 둘러싼 제반 사정을, 기대권⑤는 ‘자회사의 설립 경위 및 목적’ 등의 해당 근로관계 및 용역계약을 둘러싼 제반 사정을 종합하여 기대권 인정 여부를 판단하는 구조이다.

(1) 기대권A그룹

1) 명시적 규정(A-1)

기간 만료에도 불구하고 근로계약, 취업규칙이나 단체협약 등에 명시적 규정(A-1)이 있다면 제반 사정에 대한 고려 없이 바로 기대권이 인정된다. 때문에 기대권A그룹의 경우 근로계약, 취업규칙이나 단체협약에 ‘일정한 요건이 충족되면’ 근로계약이 갱신되거나 정규직으로 전환되거나 기간제로 재고용된다는 취지의 규정이 있는지를 먼저 확인해야 한다. 그리고 근로계약, 취업규칙, 단체협약 등에 이와 관련된 규정이 있다면 이것이 사용자에게 의무를 부여하는 규정인지 아니면 사용자의 재량에 의존하는 규정인지를 판단해야 한다. 의무규정이 아니라 사용자의 재량에 의존하는 규정이라면, 이는 제반 사정의 하나로서 다른 판단요소와 더불어 종합적으로 판단해야 한다. 예컨대 취업규칙에 “인사평가를 참작하여 이사회에서 재계약 여부를 결정할 수 있다.”라고 사용자의 재량사항으로 규정하였더라도, 실제 인사평가를 거쳐 이를 토대로 이사회에서 재계약 여부를 결정해왔다면 기대권이 인정될 수 있다(계속 고용에 관한 ‘요건이나 절차의 설정 여부 및 그 실태’의 측면).

사용자가 근로자 전체를 대상으로 회의 등을 개최하여 일정한 요건을 충족하면 계속 고용할 것이라고 약속하거나 개별 근로자에게 요건 충족 시(예컨대 건강상 특별한 사정이 없는 한) 계속 고용을 약속하는 경우가 있는데 이를 위 A-1로 볼 수 있는지 문제시된다.¹⁸⁾ 사용자의 집단적 약속은 취업규칙이나 단체협약의 규정과 맞먹을 정도의 규범성이 있어 계속 고용에 대한 집단적 신뢰관계가 형성될 정도이어야 한다(이는 후술하는 기대권 인정기준의 집단성과 관련성이 있음). 집단적 약속을 한 주체가 채용 등의 인사권을 갖는 사용자성을 가진 사람인지, 약속한 내용이 ‘일정한 요건을 충족하면’ 계속 고용하겠다는 취지인지 여부를 살펴 A-1인지를 판단하여야 한다. 관리자의 집단적 약속이 위와 같은 기준에 미치지 못한다면 이 역시 제반 사정(A-2)의 하나로 다른 판단요소와 더불어 종합적으로 판단해야 한다.

한편 사용자가 개별 근로자에게 일정한 요건 충족 시 계속 고용을 구두로 약속한 경우에도 이러한 약속이 근로계약상의 약정(A-1)으로 인정될 수 있어야 하는데 이 경우에도 위와 마찬가지로 약속의 주체와 내용 등을 통해 판단해야 한다(이는 후술하는 기대권 인정기준의 개별성과 관련성이 있음). 한편 사용자가 다른 기간제근로자와 달리 특정 근로자에게만 요건의 설정 없이 계속 고용을 약속하였다면 이는 기대권 법리가 아니라 채용 내정 법리에 준하여 판단해야 한다. 기대권은 일정한 요건을 충족하면 계속 고용될 수 있으리라는 기대상태를 권리로서 보호하는 것이기 때문이다. (개별 근로자이든 근로자 집단이든) 요건의 설정 없이 계속 고용을 약속하였다면 이는 채용 내정과 같이 새로운 근로계약의 체결로 볼 수 있는지, 즉 근로계약 체결 당사자 사이에 근로계약 체결에 대한 확정적 의사표시가 있었는지 등을 판단해야 한다.

18) 노동실무에서 이러한 구두 약속을 증명하기 위해 녹취록이 종종 등장한다.

2) 신뢰관계(A-2)

일반적으로 ‘신뢰관계’는 계약당사자 사이에 명시적·묵시적 약정(이에 준하는 것)으로 생성될 수 있을 뿐만 아니라 사업장에서 거듭되는 관행이 있는 경우에도 생성될 수 있다. 기대권A그룹은 앞서 언급한 명시적 규정(A-1)이 없더라도 제반 사정을 종합할 때 일정한 요건을 충족하면 고용이 계속된다는 신뢰관계가 형성되면 기대권이 인정되는데, 이때의 신뢰관계는 대체로 관행으로 생성된 것으로 볼 수 있다. 즉 관행은 오랫동안 동일한 행위가 반복되어 기간 만료 등에도 불구하고 갱신 등과 같은 행위가 행하여질 것이라고 일반적으로 예상할 수 있는 상태를 말한다. 만약 이러한 관행이 법적 확신까지 획득하였다면 규범성이 인정되어 A-1로 평가될 것이다.

이러한 신뢰관계가 형성되었는지 여부에 대해, 기대권① 판결은 ‘근로계약의 내용과 근로계약이 이루어지게 된 동기 및 경위, 계약 갱신의 기준 등 갱신에 관한 요건이나 절차의 설정 여부 및 그 실태, 근로자가 수행하는 업무의 내용 등’을, 기대권② 판결은 ‘근로계약의 내용과 근로계약이 이루어지게 된 동기 및 경위, 기간의 정함이 없는 근로자로의 전환에 관한 기준 등 그에 관한 요건이나 절차의 설정 여부 및 그 실태, 근로자가 수행하는 업무의 내용 등’ 당해 근로관계를 둘러싼 여러 사정을 종합하여 판단한다. 기대권①과 ②는 신뢰관계의 형성에 대한 판단요소에 별반 차이가 없는 것을 알 수 있다.

한편 기대권③ 판결은 “근로계약, 취업규칙, 단체협약 등에서 ... 재고용하여야 한다는 취지의 규정을 두고 있거나, 그러한 규정이 없더라도 ‘재고용을 실시하게 된 경위 및 그 실시기간, 해당 직종 또는 직무 분야에서 정년에 도달한 근로자 중 재고용된 사람의 비율, 재고용이 거절된 근로자가 있는 경우 그 사유 등’의 여러 사정을 종합하여 볼 때, 사업장에 ‘그에 준하는 정도의 재고용 관행’이 확립되어 있다고 인정되는 등 ... 신뢰관계가 형성”되어 있어야 한다고 판시하였

다. 즉 정년 후 재고용 기대권이 인정되기 위해서는 정년에 도달한 근로자를 기간제근로자로 재고용하여야 한다는 명시적 규정(A-1)이 존재하거나 ‘그에 준하는 정도의 재고용 관행’이 확립되어야 한다는 것이다. 대법원은 신뢰관계의 형성에 대해 앞의 기대권①·②와 달리 더욱 엄격한 판단요소를 내세운 것인데 정년 후 재고용 기대권은 ‘그에 준하는 정도의 재고용 관행’, 다시 말하면 ‘재고용하여야 한다는 취지의 규정에 있는 경우에 준하는 정도의 재고용 관행’까지 요구하고 있다. 이렇게 엄격한 판단요소를 내세운 것은 정규직으로서 정년까지 근로한 근로자의 경우 다른 기대권의 기간제근로자에 비해 상대적으로 보호필요성이 낮다고 본 것으로 보인다.

징계면직에 대해 무효로 확정 판결을 받은 근로자가 징계면직이 아니었다면 정년 후에도 재고용되었을 것이므로 재고용 연한(만 60세)까지의 임금 상당액 등을 청구하는 소송을 제기한 사안에서 대법원¹⁹⁾은 정년 후 재고용 기대권이 인정되는지 여부를 판단하였다. 사용자는 취업규칙에 직원의 정년을 만 57세(정년에 달한 분기의 말일에 퇴직)로 정하면서, 2012. 9. 무렵부터 정년퇴직자에게 1개월의 휴식기간을 준 후 이들을 기간제근로자로 재고용하고 이후 갱신을 통해 만 60세(재고용 연한)까지 근무할 수 있도록 하는 제도를 시행하였다. 이 제도가 도입된 이래로 정년에 도달한 근로자들은 모두 기간제근로자로 재고용되었으며, 정년 도래 후에도 수년 동안 정년퇴직자 스스로 재고용을 신청하지 않은 경우를 제외하면 모두 기간제근로자로 재고용되었다.²⁰⁾ 대법원은 실제 재고용을 희망하는 근로자 모두 기간제근로자로 재고용된 사실에 비추어 근로자의 정년퇴직 무렵에는 재고용

19) 대법원 2023. 6. 1. 선고 2018다275925 판결

20) 이에 대한 자세한 내용은 강선희, “정년 후 재고용 기대권 - 대상판결①: 대법원 2023. 6. 1. 선고 2018다275925 판결, 대상판결②: 대법원 2023. 6. 29. 선고 2018두62492 판결 -”, 「노동리뷰」 2023년 8월호, 한국노동연구원, 2023, 113~116면 참조

하는 관행이 성립되었다고 판단하였다.

반면 기대권③ 판결의 사안에서 대법원은 정년 후 재고용 기대권을 부인하는 판단을 하였는데 사실관계를 간략히 보면, 단체협약 및 취업규칙에는 정년퇴직자를 축탁직 근로자로 재고용할지 여부에 대해 기본적으로 사용자에게 재량을 부여하는 취지의 규정을 두고 있고, 재고용 적격 심사의 기준도 추상적으로만 제시되어 있을 뿐 일정한 기준을 충족할 경우 재고용이 보장된다는 취지의 규정은 없다.²¹⁾ 한편 근로자가 정년 퇴직하기 전 약 3년 동안 정년에 도달한 근로자 23명 중 해당 근로자 외에도 적어도 8명이 축탁직 근로자로 재고용되지 않았는데, 재고용을 희망하였으나 거절된 것인지, 거절되었다면 거절 사유가 무엇인지 등이 분명하지 않다. 초심 지방노동위원회부터 대법원에 이르기까지 취소에 취소를 거듭하였는데, 최종적으로 대법원은 위와 같은 사실관계만으로 “원고의 사업장에는 정년에 도달한 근로자를 축탁직(기간제) 근로자로 재고용하여야 한다는 단체협약 등의 규정이 존재하거나 그에 준하는 정도의 재고용 관행이 확립되어 있었다고 볼 수 없다.”라고 판시하면서 원심을 파기하였다.²²⁾ 이 사안에서 재고용 비율은 약 56.5%인데 이 정도는 명시적 규정에 있는 경우에 준하는 정도의 재고용 관행이 있다고 보기 어렵다고 판단한 것이다.

(2) 기대권B그룹

a) 기대권B그룹은 해당 근로관계 및 용역계약을 둘러싼 제반 사정

21) 단체협약 제47조: “회사는 고령화 시대의 대비와 안정적인 고용확보를 위하여 정년에 도달한 조합원을 축탁직으로 재고용하고자 하는 때에는 근로자의 과반수로 조직된 노동조합과 협의하여 재고용할 수 있다.”

취업규칙 제65조: “정년퇴직자로서 회사의 업무상 필요가 있는 경우 1년 이내의 기간을 정하여 축탁직으로 채용할 수 있다. 다만, 채용에 관하여는 다음 각 호의 기준에 따라 그 적부를 심사한 후에 결정한다.”라는 정하면서 각 호에 건강상태가 양호하여 업무수행에 지장이 없는 자(제1호), 재직 중의 근무태도, 성적 및 성격 등이 양호한 자(제2호), 재직 중 종사하고 있는 업무의 필요성이 계속 인정된 자(제3호)로 규정

22) 이에 대한 자세한 내용은 각주20)의 평석 참조

을 종합하여 기대권 인정 여부를 판단하는 구조이다. 특히 기대권B그룹은 사용자의 변경이 있고, 종전 사용자와 새로운 사용자 사이, 새로운 사용자와 종전 용역업체 근로자 사이, 도급업체와 용역업체 근로자 사이에 어떠한 법률관계도 형성되지 않기 때문에 기대권A그룹처럼 ‘A-1’와 같은 명시적 규정을 기대하기 어렵다.

b) 특히 기대권④의 경우 고용승계와 관련된 규정이 있더라도 그 규정이 승계당사자인 새로운 사용자를 구속할 수 있는 효력이 있는지가 문제시된다. 종전 용역업체 근로자들과 새로운 사용자 사이에 고용승계 관련 약정은 새로운 근로계약을 체결하는 것과 다름없으므로 법적으로 전혀 문제되지 않고, 문제의 상황이 발생할 가능성도 거의 없다. 적어도 승계당사자인 새로운 사용자에게 고용승계의무를 부과하기 위해서는 새로운 사용자가 법률관계에 개재되어야 하는데 그러한 유형이 도급업체와 새로운 사용자 사이에 ‘새로운 용역업체가 종전 용역업체 소속 근로자에 대한 고용을 승계하기로 하는 조항을 포함’(기대권④ 판결, 이하 ‘고용승계조항’이라 한다)하고 있는 경우이다. 이러한 계약만으로 승계의무가 발생한다면 기대권A그룹의 명시적 규정(A-1)이 있는 경우와 마찬가지로 다른 판단요소에 대한 고려 없이 곧바로 승계의무를 인정할 수 있을 것이다. 그러나 도급업체와 새로운 사용자 간에 고용승계조항을 체결하더라도 도급업체와 종전 용역업체 소속 근로자 사이에 어떠한 법률관계도 형성되어 있지 않기 때문에 종전 용역업체 소속 근로자는 이 계약으로부터 벗어나 있는 제3자에 불과하다.

이와 관련하여 기대권④ 판결의 원심²³⁾은 새로운 사용자의 고용승계의무를 ‘제3자를 위한 계약’(민법 제539조) 법리에서 찾았으나 대법

23) 대전고등법원 2016. 10. 7. 선고 2016누11696 판결: “이 사건 청소용역시방서의 고용승계 규정은, 이러한 규정을 특별히 명시한 취지 등에 비추어 보면, 제3자인 참가인들에게 직접 권리를 취득하게 할 목적으로 체결된 제3자를 위한 계약이라고 볼 여지도 충분하고, 이 경우 참가인들이 승낙의 의사를 표시(고용승계 요구)한 이상, 원고로서는 이 사건 청소용역시방서의 고용승계 규정에 따라 참가인들에 대하여 고용승계의무를 직접 부담한다고 할 것이다.”

원은 이를 채택하지 않았고 기대권 법리를 원용하였다. 원래 계약이 체결되면 당사자만을 구속하나, 제3자를 위한 계약은 채권자(요약자)와 채무자(낙약자) 사이의 계약(기본관계)으로부터 발생하는 권리를 계약당사자 이외의 제3자인 수익자에게 직접적으로 귀속시키는 내용을 가지는 계약²⁴⁾을 말하므로 원심은 위 고용승계조항이 이에 해당한다는 입장이다.

고용승계조항에 제3자를 위한 계약 법리를 적용하기 위해서는 두 가지 과제가 해결되어야 한다.

먼저 고용승계조항이 ‘제3자를 위한 계약’에 해당하는지 여부이다. 판례는 ‘어떤 계약이 제3자를 위한 계약에 해당하는지 여부는 당사자의 의사가 그 계약에 의하여 제3자에게 직접 권리를 취득하게 하려는 것인지에 관한 의사해석’의 문제로 보고, 이는 ‘계약 체결의 목적, 계약에서의 당사자 행위의 성질, 계약으로 인하여 당사자 사이 또는 당사자와 제3자 사이에 생기는 이해득실, 거래 관행, 제3자를 위한 계약 제도가 갖는 사회적 기능 등 제반 사정’을 종합하여 계약당사자의 의사를 합리적으로 해석함으로써 판별할 수 있다고 한다.²⁵⁾ 원심은 위 고용승계조항이 종전 용역업체 소속 근로자를 제3자(수익자)로 하는 도급업자(요약자)와 새로운 사용자(낙약자) 간의 계약으로 이에 해당한다고 본 것이다.²⁶⁾ 그러나 기대권^④ 판결의 대법원이 이를 인정하

24) 대법원 1957. 3. 16. 선고 4298민상536 판결, 대법원 2006. 1. 12. 2004다46922 판결 등

25) 대법원 2021. 8. 19. 선고 2018다244976 판결 등

26) 도급업체와 새로운 용역업체 간에 체결한 용역계약서의 일부로 청소용역시방서를 체결하였고, 청소용역시방서에는 아래와 같은 내용이 포함되어야 있다.

II. 일방시방서

제10조(종업원의 채용 및 퇴·해직)

① 계약상대자는 종업원을 채용하고자 할 때는 당해 업무를 수행할 자만을 채용하여야 하며, 특별한 사정이 없는 한 현재 근무하고 있는 종업원을 고용승계 및 용역계약기간 중 고용유지하여야 한다.

III. 특기시방서

거나 언급함이 없이 여러 판단요소를 종합적으로 판단하는 기대권 법리를 전개한 사실에 비추어 보면 고용승계조항은 제3자를 위한 계약에 해당하지 않는다고 판단한 것으로 보인다.

다음으로 고용승계조항이 제3자를 위한 계약이라면 도급업체(요약자)와 종전 용역업체 소속 근로자(수익자, 제3자) 사이의 관계, 즉 요약자가 자기가 취득할 권리를 수익자에게 귀속하게 하는 원인 내지 이유가 되는 관계(대가관계²⁷⁾)에서 발생하는 문제이다. 요약자와 수익자 사이의 관계(대가관계)는 내부관계에 불과하기 때문에 요약자와 낙약자 사이에 체결된 계약 자체와 아무 관계가 없고, 대가관계의 흠결이나 하자는 제3자를 위한 계약의 성립 및 효력에 영향을 주지 않는다.²⁸⁾ 다시 말하면 대가관계가 결여되었더라도 제3자를 위한 계약의 성립에 아무런 영향을 미치지 않으나 제3자가 낙약자로부터 수령한 급부는 요약자와의 관계에서는 법률상 원인이 없는 것이므로 부당이득을 이유로 요약자에게 반환(민법 제741조)하여야 한다.²⁹⁾ 이러한 법리를 위 고용승계조항에 대비하면 도급업체(요약자)와 종전 용역업체 소속 근로자(수익자) 간에 법률관계가 없더라도 고용승계조항을 포함한 약정(제3자를 위한 계약)의 성립에는 지장이 없다고 볼 수 있다. 그러나 종전 용역업체 소속 근로자와 도급업체 사이에 법률상 원인이 없으므로 민법 제741조 부당이득법에 따라 도급업자(요약자)는 제3자인 근로자에게 이미 이행된 것의 반환이나 급부청구권의 양도를 구할

4. 청소인원

라. 계약상대자는 청소용역 작업원 확보시 Y의 특수성을 고려하여 특별한 경우를 제외하고는 기존 청소업체 종업원의 재 채용을 원칙으로 하며, 결원자의 신규 채용시는 Y의 인근주민을 채용하되 인근 주민의 수급이 불가능할 때는 감독원의 승인을 받아 타지역 인원을 채용할 수 있으며, 채용된 작업원은 특별한 사유가 없는 한 용역계약기간 중 고용을 유지해야 한다.

27) 대법원 2003. 12. 11. 선고 2003다49771 판결 등

28) 대법원 2003. 12. 11. 선고 2003다49771 판결

29) 지원림, 「민법강의」 제9판, 홍문사, 2011, 1364~1365면.

수 있을 것이나 근로관계에 이와 같은 부당이득법을 적용할 수 있는지는 많은 의구심이 있을 뿐만 아니라 적용하기 어렵다고 보아야 한다. 이와 같은 측면을 고려하면 대법원이 제3자를 위한 계약 법리를 채택하기 어려웠을 것으로 보이고, ‘새로운 용역업체가 종전 용역업체 소속 근로자에 대한 고용을 승계하기로 하는 조항을 포함하고 있는지 여부를 포함한 구체적인 계약내용’만으로 고용승계기대권을 인정하기 부족하다고 판단하고 ‘그 밖의 판단요소’(‘해당 용역계약의 체결 동기와 경위, 도급업체 사업장에서의 용역업체 변경에 따른 고용승계 관련 기존 관행, 위탁의 대상으로서 근로자가 수행하는 업무의 내용, 새로운 용역업체와 근로자들의 인식 등 근로관계 및 해당 용역계약을 둘러싼 여러 사정’)와 더불어 종합적으로 고려하여 판단하는 구도를 취한 것으로 보인다.

생각전대 고용승계조항이 규범력이 없는 단순한 신사협정이 아닌 이상 민법전에 규정한 전형적인 계약의 유형을 찾으려는 수고에 앞서 계약은 지켜져야 한다하는 대원칙(“*pacta sunt servanda*”)에 따라 고용승계조항이 있다면 이를 부인할 만한 특별한 사정이 없는 한 새로운 사용자는 고용승계의무를 부담한다고 판단해야 한다. 그리고 이때의 부인할 만한 특정한 사정은 이러한 규정이나 약정이 규범력이 없어 형식에 불과하여 신사협정에 지나지 않는다는 사정을 말하고, 이는 위 ‘그 밖의 판단요소’를 통해 확인할 수 있을 것이다.³⁰⁾

c) 기대권⑤의 경우 도급업체가 용역업체에 위탁하여 수행하던 업무를 자회사 설립을 통해 이에 위탁하는 경우이므로 종전 용역업체 소속 근로자에 대해 계속 고용의무를 부담할 주체는 자회사이다. 도급업체가 자회사를 설립한 주체이므로 주체의 동질성이 인정되기 때문에 기대권A그룹이나 기대권④와 같이 종전 용역업체 소속 근로자를 정규직으로 채용한다는 명시적인 규정이나 약정을 필요로 하지 않

30) 강선희, “기간제근로자의 고용종료를 보호하기 위한 판례 법리”, 295면 참조

는다. 이러한 이유로 ‘해당 근로관계 및 용역계약을 둘러싼 여러 사정’(‘자회사의 설립 경위 및 목적, 정규직 전환 채용에 관한 협의의 진행경과 및 내용, 정규직 전환 채용 요건이나 절차의 설정 여부 및 실태, 기존의 고용승계 관련 관행, 근로자가 수행하는 업무의 내용, 자회사와 근로자의 인식 등’)을 종합적으로 고려하여 판단하는 구조이다.

d) 기대권B그룹은 기대권A그룹과 달리 판단요소에 ‘새로운 용역업체나 자회사와 근로자들의 인식’을 부가하고 있는데 이는 사용자가 변경되기 때문으로 보인다. 이에 해당하는 구체적 사정이 무엇인지는 아직까지 확인되지 않는데 이를 추론할 만한 사정은 ‘도급업체 사업장에서의 용역업체 변경에 따른 고용승계 관련 기존 관행’과의 관계에서 확인할 수 있을 것이다(기대권④의 경우). 즉 이 판단요소는 도급업체와 새로운 용역업체 사이에 고용승계조항을 포함한 용역계약을 체결하지 않은 상태에서 도급업체 사업장에서 용역업체 변경에 따른 고용승계 관련 기존 관행이 형성되어 있는 사정만으로 새로운 용역업체에게 고용승계의무를 인정할 수 있는지 여부와 관련된 것으로 볼 수 있다. 기대권④ 판결에 이어 나온 후속 판결(대법원 2021. 6. 3. 선고 2020두45308 판결)³¹⁾의 사안을 보면 명시적인 고용승계조항은 없었으나 새로운 용역업체가 예전에도 도급업체 사업장에서 용역을 수행한 적이 있고, 그 당시에조차도 종전 용역업체 소속 근로자의 고용을 승계한 사실이 있어 고용승계 관행을 충분히 알았던 점에 비추어 새로운 용역업체는 자신이 고용승계의무를 부담한다는 점을 인식하고 있었던 것으로 보인다. 즉 새로운 용역업체에게 고용승계의무를 부과하기 위해서는 적어도 자신이 어떠한 의무를 부담해야 하는지를 알았거나 알 수 있어야 하므로, 새로운 용역업체는 종전 용역업체 소속 근로자의 고용을 승계하는 관행이 있는 것을 알았거나 알 수 있어야

31) 이 판결에 대한 자세한 내용은 강선희, “위탁 등 아웃소싱과 노동법적 쟁점-기간제 근로자를 중심으로-”, 172~177면 참조

한다.³²⁾ 한편 기대권⑤의 경우 앞서 언급하였듯이 도급업체가 자회사를 설립하여 주체의 동질성이 인정되므로 ‘자회사의 인식’은 특별한 사정이 없는 한 별도로 고려하지 않아도 될 것이다.

2. 기대권 인정기준의 단위

계속 고용에 대한 기대권은 근로자 개인이 갖는 주관적 희망(기대)을 말하는 것이 아니라 ‘근로계약 당사자 사이에 일정한 요건이 충족되면’ 근로계약이 갱신되거나 정규직으로 전환되거나 기간제로 재고용된다는 객관적 ‘실회관계’(기대권A그룹), ‘근로관계 및 해당 용역계약을 둘러싼 여러 사정’을 통해 새로운 용역업체 또는 자회사가 고용을 승계하거나 정규직으로 채용하여 새로운 근로관계가 성립될 것이라는 객관적 ‘실회관계’(기대권B그룹)를 말한다. 이러한 객관적 기대는 그 성질(명시적 규정이나 오랫동안 동일한 행위가 반복되어 기간 만료 등에도 불구하고 갱신 등과 같은 행위가 행하여질 것이라고 일반적으로 예상할 수 있는 상태)에 비추어 해당 사업장 또는 현장 단위로 형성되는 것이 원칙일 것이다. 그러나 개별적인 근로계약 등을 통해 근로자별로 기대권이 형성될 수도 있다. 따라서 기대권의 인정 여부를 해당 사업장 또는 현장 등의 집단 전체를 기준으로 판단할 것인지 아니면 개별 근로자를 기준으로 판단할 것인지 문제시될 수 있다.³³⁾

(1) 기대권A그룹

1) 기대권①과 ②

기대권A그룹의 경우 판례가 ‘근로계약 당사자 사이’라고 표현하여

32) 현실적으로 해당 분야에서 용역사업을 계속하였던 사용자라면 이러한 관행의 존재에 대해 충분히 알았거나 알 수 있었을 것으로 보인다.

33) 사실상 무기계약 법리는 오로지 개별 근로자를 단위로 판단해야 한다.

기대권 인정 여부가 마치 개별 근로자에 따라 달라질 수 있는 것처럼 비취질 수 있으나 이는 사용자의 변경 없이 동일한 사용자를 대상으로 한다는 측면에서 표현한 것으로 파악해야 한다. 기대권은 원칙적으로 해당 사업장이나 현장에서 개별 근로계약 당사자의 주관적 의사와 상관없이 형성된 객관적 상황(여건) 내지 신뢰관계로 보아야 한다. 다만 기대권①과 ②의 경우 일정한 요건이 충족되면 계약이 갱신되거나 정규직으로 전환한다는 취지의 규정을 ‘근로계약’으로 정한 경우, ‘근로계약의 내용과 근로계약이 이루어지게 된 동기 및 경위’ 또는 ‘근로자가 수행하는 업무의 내용 등’과 관련된 경우에는 개별 근로자별로 기대권의 인정 여부를 달리 판단할 수 있다. 이를 구체적으로 살펴본다.

기대권①과 ②에서 해당 사업장 또는 현장 단위로 기대권을 판단해야 하는 이유는 ‘취업규칙이나 단체협약’에 일정한 요건이 충족되면 근로계약이 갱신된다는(정규직으로 전환된다는) 취지의 규정 또는 그러한 규정이 없더라도 ‘계약 갱신의 기준 등 갱신에 관한(정규직 전환에 관한) 기준 등 그에 관한 요건이나 절차의 설정 여부 및 그 실태’ 등 당해 근로관계를 둘러싼 여러 사정을 종합하여 볼 때 형성된 신뢰관계이기 때문이다. 취업규칙이나 단체협약상의 규정 또는 ‘요건이나 절차의 설정 여부 및 그 실태’는 해당 사업장 또는 현장에 적용되거나 형성된 것으로 개별 근로자에 따라 달리 정해지거나 형성될 수 있는 성질의 것이 아니다(취업규칙이나 단체협약상 ‘규정’에 따른 일정한 요건의 충족 여부는 개별 근로자에 따라 달라질 수 있는데 이는 계속 고용의 거절에 대한 ‘합리적인 이유’일 뿐 기대권 인정 요소가 아니다).

다만 이 경우에도 일정한 요건을 충족하면 근로계약이 갱신된다는(정규직으로 전환된다는) 취지의 규정을 ‘개별 근로계약’으로 두고 있거나, ‘근로계약의 내용과 근로계약이 이루어지게 된 동기 및 경위’ 또는 ‘근로자가 수행하는 업무의 내용 등’에 따라 기대권 인정 여부가

달라질 수 있으므로 이와 같은 경우에는 개별 근로자에 따라 기대권 인정 여부를 달리 판단해야 한다. 다시 말하면 해당 사업장 또는 현장 전체에 기대권이 인정되거나 부인되더라도 ‘근로계약의 내용과 근로계약이 이루어지게 된 동기 및 경위’ 또는 ‘근로자가 수행하는 업무의 내용 등’에 비추어 사업장의 집단과 달리 개별 근로자에게 기대권이 인정되거나 부인될 수 있다.³⁴⁾ 예컨대 사업장에서 사용기간의 제한(2년)을 받는 일반적인 기간제근로자와 달리 육아휴직이나 파견 등으로 결원이 발생하여 대체 채용된 기간제근로자의 경우에는 특별한 사정이 없는 한 사업장의 다른 기간제근로자에 대해 기대권이 인정되더라도 대체 채용된 기간제근로자에게는 기대권이 부인될 가능성이 크다. 또한 사업장에서 다른 기간제근로자의 근로계약에는 일정한 요건을 충족하면 계속 고용된다는 취지의 조항이 있으나 이와 달리 근로계약에 이러한 조항이 없고(and), 이러한 조항이 없는 데에 합리적 이유나 특별한 사정이 있다면 해당 근로계약의 개별 근로자만 기대권이 부인될 수 있다. 이의 역도 성립될 수 있다. ‘근로자가 수행하는 업무의 내용’에 따라서도 개별 근로자별로 달리 판단할 가능성이 있는데, 예컨대 경비용역업체에서 경비업무에 종사하는 기간제근로자와 달리 한시적 필요에 따라 다른 업무에 기간제근로자를 사용하는 경우 경비업무를 수행하는 기간제근로자와 별도로 기대권 인정 여부를 판단할 수 있다.

요컨대 개별 근로자를 기준으로 기대권을 판단하는 것은 사용자가 개별 근로자에게 다른 근로자와 달리 계속 고용할 것이라는 주관적 희망을 주었는지 여부가 아니라 해당 근로계약 당사자 사이에 개별

34) 김홍영 교수는 “‘근로계약의 내용과 근로계약이 이루어지게 된 동기 및 경위’에서 어떠한 점을 살펴보아야 하는지가 문제되는데, 연장이 가능하다고 근로자가 생각할 만한 사정이 있는가를 중심으로 판단하여야 한다.”라고 하는데 이는 개별 근로자를 기준으로 판단해야 한다는 취지로 서술한 것이지 개별 근로자가 갖는 주관적 기대나 희망을 말하는 것으로 보이지 않는다(“기간제 근로자의 고용 보장 법리-갱신기대권 법리의 검토”, 『법학논총』 제39권 제2호, 한양대학교 법학연구소, 2022, 224면).

근로계약을 통해 일정한 요건을 충족하면 계속 고용한다는 취지의 규정을 두고 있는지 여부를 판단하거나, ‘근로계약의 내용과 근로계약이 이루어지게 된 동기 및 경위’나 ‘근로자가 수행하는 업무의 내용 등’에 비추어 기대권의 인정 여부를 개별 근로자별로 달리 판단할 수 있다는 의미이다. 이는 인정기준의 판단 단위를 말하는 것일뿐 개별 근로자가 갖는 주관적 기대를 배제하는 것은 아니다. 사용자 측에서 다른 근로자와 달리 계속 고용에 대한 기대를 가지게 할 만한 연사가 있었다면 개별 근로자에게 기대권이 긍정되기 쉬울 것이다.

2) 기대권③

기대권③의 경우 일정한 요건을 충족하면 기간제근로자로 재고용한다는 취지의 규정을 개별 근로계약으로 두고 있는 경우를 제외하고 기대권 인정기준은 사업장 또는 현장 단위로 판단할 수밖에 없다. 왜냐하면 ‘취업규칙이나 단체협약 등’에 정년에 도달한 근로자가 일정한 요건을 충족하면 기간제근로자로 재고용하여야 한다는 취지의 규정을 두고 있거나, 그러한 규정이 없더라도 ‘재고용을 실시하게 된 경위 및 그 실시기간, 해당 직종 또는 직무 분야에서 정년에 도달한 근로자 중 재고용된 사람의 비율, 재고용이 거절된 근로자가 있는 경우 그 사유 등’의 여러 사정을 종합하여 볼 때, ‘사업장에 그에 준하는 정도의 재고용 관행이 확립되어 있다고 인정’되는 경우이기 때문이다. 즉 정년에 도달한 근로자를 기간제근로자로 재고용하여야 한다는 취업규칙이나 단체협약의 규정과, ‘사업장’에 ‘그에 준하는 정도’(재고용하여야 한다는 취지의 규정이 있는 경우에 준하는 정도)의 ‘재고용 관행’은 개별 근로자에 따라 달리 정해지거나 형성될 수 있는 성질의 것이 아니라 ‘사업장’ 단위로 적용되거나 형성되는 것이기 때문이다. 따라서 기대권③의 경우 ‘정년’의 성질에 비추어 사업장 단위로 적용될 것이므로 개별 근로계약으로 정하는 것이 드문 사례이겠지만 개별 근로계약으로 정년 후에 재고용한다는 취지의 규정을 둔 경우를 제외하면

기대권 인정기준은 사업장 단위가 될 것이므로 개별 근로자별로 기대권 인정 여부가 달라지지 않을 것이다. 다만, 기대권 성립을 부인할 만한 ‘특별한 사정’에 대한 판단기준이 사업장 사정인지 아니면 근로자 개별의 사정인지에 따라 개별 근로자별로 기대권 인정 여부가 달라질 수 있다(Ⅲ. 3. 참조).

(2) 기대권B그룹

기대권B그룹(기대권④·⑤)은 기대권③과 마찬가지로 기대권 성립을 부인할 만한 ‘특별한 사정’에 대한 판단을 별론으로 하면 신뢰관계 형성 여부는 해당 사업장 및 현장 단위를 기준으로 판단해야 할 것이다. 이는 새로운 사용자와 개별 근로자 사이에 어떠한 법률관계도 형성되어 있지 않기 때문이기도 하다. 기대권④의 경우 ‘새로운 용역업체가 종전 용역업체 소속 근로자에 대한 고용을 승계하기로 하는 조항을 포함하고 있는지 여부를 포함한 구체적인 계약내용, 해당 용역계약의 체결 동기와 경위, 도급업체 사업장에서의 용역업체 변경에 따른 고용승계 관련 기존 관행, 위탁의 대상으로서 근로자가 수행하는 업무의 내용, 새로운 용역업체와 근로자들의 인식 등 근로관계 및 해당 용역계약을 둘러싼 여러 사정’을 종합적으로 고려하여 판단하기 때문에 해당 사업장 내지 현장별로 인정 여부가 달라질 뿐이다. 이와 같은 사정은 개별 근로자를 기준으로 판단될 성질의 것이 아니기 때문이다. 이러한 측면에서 새로운 사용자가 부담해야 하는 고용승계의무는 종전 업체의 근로자별로 부담하는 것이 아니라 종전 업체에서 종사하던 근로자 전체의 고용을 승계할 의무이다.³⁵⁾ 따라서 기대권④에

35) 강선희, “위탁 등 아웃소싱과 노동법적 쟁점-기간제근로자를 중심으로-”, 177~178면. 이러한 측면에서 같은 사업장에서 장기간 근로계약을 반복하여 갱신하거나 체결하면서 오랫동안 근로한 근로자와 그렇지 않은 근로자 사이에 고용승계기대권의 인정 여부를 달리 판단할 수 없다고 보았다. 역으로 근로자의 일부가 장기간 근무한 사정만으로 새로운 용역업체에게 해당 근로자에 대해서만 고용승계기대권을 인정하는 것도 아니다.

서 기대권 인정 여부를 판단할 때에는 용역업체의 변경에 따라 고용 변동이 발생하는 해당 업체 자체를 기준으로 판단해야 한다.

기대권⑤의 경우도 기대권④와 크게 다르지 않다. ‘자회사의 설립 경위 및 목적, 정규직 전환 채용에 관한 협의의 진행경과 및 내용, 정규직 전환 채용 요건이나 절차의 설정 여부 및 실태, 기존의 고용승계 관련 관행, 근로자가 수행하는 업무의 내용, 자회사와 근로자의 인식 등 해당 근로관계 및 용역계약을 둘러싼 여러 사정’은 개별 근로자에 따라 달라질 내용이 아니기 때문에 이 역시 자회사의 정규직으로 전환되어 채용될 종전 용역업체 소속 근로자 전체를 기준으로 판단해야 한다.

3. 기대권 형성을 부인할 만한 ‘특별한 사정’

(1) 개요

기대권①·②는 계속 고용에 대한 명시적 규정이나 신뢰관계가 형성되었다면 곧바로 기대권이 인정되는 반면, 기대권③·④·⑤는 계속 고용에 대한 신뢰관계가 형성되어 있더라도 ‘특별한 사정’이 있다면 기대권이 인정되지 않을 수 있다. 이를 도식화하면 아래와 같다.

기대권①·② : 명시적 규정(A-1) or 신뢰관계(A-2) → 기대권 인정
 기대권③: 명시적 규정(A-1) or 신뢰관계(A-2) → 특별한 사정이 없다면 → 기대권 인정
 기대권④·⑤: 신뢰관계 → 특별한 사정이 없다면 → 기대권 인정

기대권 인정 여부에 특별한 사정이 없을 것을 요하는 판결 내용을 보면 아래와 같다.

기대권③ 판결: 근로계약, 취업규칙, 단체협약 등에서 ... 기간제근로자로 재고용하여야 한다는 취지의 규정을 두고 있거나(i), 그러한

규정이 없더라도 ... 기간제근로자로 재고용될 수 있다는 신뢰관계가 형성되어 있는 경우(ii)에는 특별한 사정이 없는 한 근로자는 그에 따라 정년 후 재고용되리라는 기대권을 가진다.

기대권④ 판결: 새로운 용역업체가 종전 용역업체 소속 근로자에 대한 고용을 승계하여 새로운 근로관계가 성립될 것이라는 신뢰관계가 형성되었다면, 특별한 사정이 없는 한 근로자에게는 그에 따라 새로운 용역업체로 고용이 승계되리라는 기대권이 인정된다.

기대권⑤ 판결: 자회사가 용역업체 소속 근로자를 정규직으로 채용하여 새롭게 근로관계가 성립될 것이라는 신뢰관계가 형성되었다면, 특별한 사정이 없는 한 근로자에게는 자회사의 정규직으로 전환 채용될 수 있으리라는 기대권이 인정된다.

기대권③의 경우 ‘특별한 사정’이 (ii)만을 한정하는 것인지 아니면 (i)와 (ii) 모두를 한정하는 것인지 먼저 확정해야 한다. 정년 후 기간제근로자로 재고용해야 한다는 취지의 명시적 규정(i)이 있는 경우에는 기대권①·②과 마찬가지로 곧바로 기대권을 인정해야 하는 것은 아닌지라는 의구심을 제기할 수 있을 것이다. 그러나 문장의 구조를 보면 (i)와 (ii) 모두에 한정된 것으로 보인다.

이와 같이 대법원이 ‘특별한 사정’을 기대권 인정기준에 개재시킨 것은 기대권①·②와 달리 기대권 형성을 부인할 만한 사정을 개방한 판시내용으로 볼 수 있다. 그러나 이때의 ‘특별한’ 사정은 기왕에 형성된 신뢰관계를 부인하는 것이므로 가급적 엄격하게 해석해야 한다. 더욱이 그 사정은 때에 따라 기대권이 인정될 경우 계속 고용을 거부할 ‘합리적 이유’가 될 수도 있으므로 기대권 형성을 저지하는 예외적인 ‘특별한 사정’으로 포섭하여 판단하기보다 ‘합리적 이유’로 해결하는 것이 타당하다. 한편 그 사정을 어디에 포섭하여 판단할지는 ‘특별한 사정’과 ‘합리적 이유’에 대한 증명책임의 주체와 밀접하게 관련되어 있는데, 동일인(특히 사용자)이 부담할 경우에는 이를 엄격하게 구별하여 어느 한쪽으로 포섭하여 판단할 실익이 크지 않을 수 있으나 근로자와 사용자가 나누어 부담할 경우에는 소송의 승패를 좌우하는 중요한 문제가 된다.

기대권의 존재에 대한 증명책임은 이를 주장하는 근로자가 부담한다고³⁶⁾ 보는 한편, 합리적 이유의 증명책임은 사용자가 부담한다고 본다.³⁷⁾ 기대권의 증명내용은 재고용 등으로 고용이 계속될 수 있다는 개인적 내지 주관적 기대를 증명하는 것이 아니라 ‘일정한 요건이 충족되면’ 고용이 계속된다는 규정 또는 신뢰관계(기대권A그룹), 새로운 용역업체나 자회사에 고용이 승계되거나 채용된다는 신뢰관계(기대권B그룹)의 존재를 증명하는 것이다. 이러한 측면에서 보면 기대권 형성을 방해하는 ‘특별한 사정’은 기대권 존재에 대한 증명책임을 부담하는 근로자가 부담한다고 볼 여지가 있다. 그러나 증명책임을 분배에 관한 통설이자 판례인 법률요건분류설에 따르면 각 당사자는 자기에게 유리한 법규의 요건사실의 존부에 대하여 증명책임을 부담하는데, 권리의 발생요건을 정하는 권리근거규정은 권리의 존재를 주장하여 권리구제를 청구하는 권리주장자가, 그 권리발생의 장애요건을 정하는 권리장애규정, 그 권리행사를 일시적으로 저지하는 요건을 규정하는 권리행사저지규정, 그 권리의 소멸요건을 정하는 권리소멸규정은 그 상대방이 증명책임을 부담한다.³⁸⁾ 이러한 측면에서 보면 계속 고용에 대한 신뢰관계가 존재함에도 기대권 형성을 방해하는 ‘특별한 사정’은 권리장애규정의 요건사실(권리장애사실)로 볼 수 있다. 따라서 신뢰관계가 형성되었음에도 특별한 사정이 있어 기대권이 발생하지 않았다고 주장하는 당사자인 사용자가 증명책임을 부담한다고 보아야 한다. 요컨대 ‘특별한 사정’과 ‘합리적 이유’에 대한 증명책임

36) 도재형·노상현·최지윤, 「갱신기대권(정규직 전환기대권) 관련 판단기준에 대한 연구」(중앙노동위원회 학술연구용역사업), 중앙노동위원회, 2018, 31~32면; 오윤식, “기간제 근로자의 근로계약 갱신기대권 법리”, 「민주법학」 제50호, 민주주의법학연구회, 2012, 496~497면.

37) 대법원 2017. 10. 12. 선고 2015두44493 판결

38) 이시운, 「신민사소송법」 제10판, 박영사, 2016, 541면 이하 참조. 권리장애규정은 권리근거규정의 요건이 존재함에도 불구하고 예외적으로 권리발생을 방해하는 사유에 대하여 규정한 경우로서, 권리근거규정과 권리장애규정의 관계는 원칙규정과 예외규정의 관계라고 한다.

모두 사용자가 부담하여 이를 구별하여 판단할 큰 실익은 없더라도 앞서 언급하였듯이 특별한 사정은 기대권 형성을 저지하는 예외적 사유이므로 엄격하게 판단해야 한다.

(2) ‘특별한 사정’이란

기대권³⁹의 경우 명시적 규정이나 그에 준하는 정도의 재고용 관행이 형성되었음에도 이를 인정하지 못할 만한 ‘특별한 사정’이 무엇인가? 명시적 규정을 설정할 당시에 당사자가 예견하지 못한 또는 예견할 수 없었던 사정이 재고용을 거부하는 시점³⁹에 발생하여 명시적 규정에 따라 객관적으로 재고용을 기대할 수 없는 상황이 발생한 경우가 있을 수 있다. 또한 재고용에 대한 신뢰관계 형성 시점 전후로 계속 고용을 기대할 수 없는 특별한 사정의 발생 등을 예상할 수 있다. 특별한 사정은 사업장 단위에서 또는 개별 근로자에게서 발생할 수 있을 것으로 보이나 원칙적으로 사업장 단위에서 발생한 것으로 보아야 하고, 개별 근로자에게 발생한 사정이더라도 주관적 사정이 아니라 객관적 사정을 의미한다고 새겨야 한다. 기대권⁴·⁵도 위와 마찬가지로 계속 고용에 대한 신뢰관계 형성 시점을 전후로 사용자의 변경 등으로 예측하지 못한 사정이 발생하여 계속 고용을 기대할 수 없는 상황이 발생한 경우이다.

이와 관련하여 경영상 이유에 의한 해고(근로기준법 제24조)를 할 정도의 ‘긴박한 경영상 필요성’이 발생한 경우를 여기서 말하는 특별한 사정으로 볼 수 있는지 여부가 문제된다.

기대권¹·²의 경우 경영상 이유에 의한 해고(근로기준법 제24조)를 할 정도로 ‘긴박한 경영상 필요성’이 있거나 갱신 거부를 해야 할

39) 기대권이 인정되는지 여부 판단의 기준 시점은 원칙적으로 사용자의 갱신 거절 당시, 즉 기간제 근로계약의 종료 당시를 기준으로 한다(서울고등법원 2016. 10. 13. 선고 2016누50978 판결).

‘경영상 또는 운영상의 필요’가 있는 사정은 ‘합리적 이유’로 고려된다.⁴⁰⁾ 이의 경우는 기대권 형성을 방해할 만한 ‘특별한 사정’이 개재되어 있지 않으므로 위와 같은 사정은 논리적으로 합리적 이유에서 고려되는 것이 타당하다.

생각건대 일반적으로 계속 고용을 거부할 만한 ‘경영상 또는 운영상의 필요’가 있는 사정은 ‘합리적 이유’로 고려해야 하고, 경영상 이유에 의한 해고를 할 정도로 ‘긴박한 경영상 필요성’도 원칙적으로는 ‘합리적 이유’에서 판단하되 예외적으로만 ‘특별한 사정’으로 고려될 수 있다. 이러한 예외는 그 사정의 발생 시점에 따라 달라질 수 있을 것으로 보인다.

기대권③의 경우 정년 후 재고용하기로 하는 명시적 규정이 있으나 해당 근로자가 정년에 도달하기 전에 긴박한 경영상의 필요성이 있는 사정이 이미 발생하여 위와 같은 명시적 규정에도 불구하고 사정변경으로 재고용되리라고 객관적으로 기대할 수 없는 상황이 명백한 경우이다. 예컨대 취업규칙에 건강상 문제가 없다면 정년 후에도 1년 단위로 최대 3년까지 기간제근로자로 재고용하기로 정한 규정이 있는 운수회사에서, 해당 근로자가 정년에 도달하기 전에 운행차량의 30% 감차로 기간제근로자의 기간 만료 등으로 감원하는 것뿐만 아니라 추가적으로 고용조정을 해야 할 상황이 객관적으로 발생한 경우이다. 상황이 이와 같다면 명시적 규정이 있음에도 당사자 간에 정년 후에도 기간제로 재고용되리라고 기대하기 어려울 것이다. 그러나 긴박한 경영상의 필요성에 대하여 당사자 간에 다툼이 있거나, 긴박한 경영상의 필요성이 명백함에도 정년에 도달한 근로자 전부가 아니라 그중 일부만을 선택적으로 재고용을 거부하는 경우라면 이는 ‘합리적 이유’에서 판단하여야 한다.

기대권B그룹의 경우 앞서 살펴보았듯이 근로자별로 신뢰관계의 형

40) 대법원 2017. 10. 12. 선고 2015두44493 판결

성 여부를 달리 판단할 수 없으나 일단 신뢰관계가 형성되어 있다면 기대권의 성립을 저지할 만한 특별한 사정은 개별 근로자에게서 또는 사업장 단위에서 발생할 수 있다. 예컨대 취업규칙으로 근로할 수 있는 연령의 최대한도를 70세로 정한 경우 70세에 도달하는 근로자에게 계속 근로에 대한 객관적 기대가 형성되었다고 보기 어렵기 때문에 종전 용역업체 소속 근로자 전체에게 고용승계기대권이 인정되더라도 70세에 도달한 개별 근로자에게는 기대권이 인정되지 않을 수 있다. 여기에서 근로할 수 있는 최대연령은 특별한 사정이 될 수 있다. 이러한 측면에서 기대권B그룹의 경우, 계속 고용에 대한 신뢰관계의 형성 여부는 승계 대상이 되는 해당 사업장 단위를 기준으로 판단하기 때문에 특별한 사정은 주로 개별 근로자에게서 발생할 가능성이 크다. 개별 근로자에게서 발생하는 ‘특별한 사정’은 계속 고용에 대한 신뢰관계가 승계 대상인 종전 용역업체 단위로 형성되었음에도 개별 근로자에게 계속 고용을 객관적으로 기대하기 어려운 사정을 말한다고 볼 수 있다.⁴¹⁾

IV. 계속 고용 거절의 합리적 이유

1. 일반론

계속 고용에 대한 기대권이 인정되는 경우 사용자가 계속 고용(갱신, 정규직으로 전환, 재고용, 고용승계 및 정규직으로 전환 채용)을 합리적 이유 없이 거절하는 것은 부당해고와 마찬가지로 근로자에게 효력이 없다(기대권①~⑤ 판결). 즉 계속 고용에 대한 기대권이 형성

41) 강선희, “위탁 등 아웃소싱과 노동법적 쟁점-기간제근로자를 중심으로-”, 179-180면 참조. 이는 해당 근로자의 승계 거부의 합리적 이유를 판단하는 것이 아니라 객관적으로 보아 해당 근로자에게 고용승계기대권을 인정하기 어려운 사정이 있는지를 판단하는 것임을 유의해야 한다.

되어 있음에도 사용자가 갱신 거절 등으로 근로관계를 강제로 종료하는 것은 근로자에게는 ‘해고’와 다를 바 없기 때문에 기간 만료, 정년 및 용역업체의 변경 등을 원인으로 한 고용종료에 해고제한법리(근로기준법 제23조 제1항과 제28조)를 유추 적용하는 것이다.⁴²⁾ 따라서 근로자에게 정당한 기대권이 인정될 경우 사용자의 계속 고용 거절에 사회통념상 상당하다고 인정되는 합리적 이유가 있어야 하는데⁴³⁾, 여기서 판례는 ‘합리적 이유’는 해고의 기준인 ‘정당한 이유’보다 완화된 기준으로서 그 유효성을 해고보다는 넓게 인정된다고 본다.⁴⁴⁾ 계속 고용의 거절이 ‘해고와 마찬가지로’의 효과가 나타날 뿐 근로기준법 제23조 제1항의 ‘해고’ 자체는 아니므로 근로기준법 제23조 제1항의 ‘정당한 이유’보다 완화된 ‘합리적 이유’를 요하는 것으로 볼 수 있다. 사용자가 강행법규에 반하여 차별적으로 계속 고용을 거절하거나⁴⁵⁾ 설령 그것이 벌칙이 적용되는 의미에서 강행법규 위반죄가 성립하지 않더라도 헌법 제11조의 평등권 및 개별법률로 차별을 금지하는 입법 취지 등을 고려하여 합리적 이유가 없다고 보아야 한다.⁴⁶⁾ 또한 사용자는 성희롱 발생 사실을 신고한 근로자와, 직장 내 성희롱과 관련하

42) 자세한 내용은 강선희, “기간제근로자의 고용종료를 보호하기 위한 판례 법리”, 262~267면 참조

43) 서울고등법원 2005. 12. 13. 선고 2004누24587 판결

44) 서울고등법원 2012. 9. 5. 선고 2012누1282 판결

45) 유사한 취지로 대법원 2017. 10. 12. 선고 2015두44493 판결

46) 근로기준법 제6조에 사용자는 근로자에 대하여 남녀의 성(性), 국적·신앙 또는 사회적 신분을 이유로 근로조건에 대한 차별적 처우를 하지 못한다고 정하고 있다(벌칙 제114조). 또한 남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률(이하 ‘남녀고용평등법’이라 한다)은 제7조 제1항에 모집·채용(벌칙 제37조 제4항), 제11조 제1항에 해고뿐만 아니라 정년·퇴직 등의 고용종료(벌칙 제37조 제1항)에 남녀 차별이 금지된다. 장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률은 모든 생활영역에서 장애를 이유로 한 차별을 금지하면서 제10조에 모집·채용에서부터 정년·퇴직·해고에 이르기까지 차별을 금지하고 있다(벌칙 제49조). 고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률 제4조의4는 모집·채용에서부터 퇴직·해고에 이르기까지 연령을 이유로 한 차별을 금지하고 있다.

여 피해를 입었거나 입었다고 주장하는 근로자에 대해 해고 그 밖에 신분상실에 해당하는 불이익 조치를 하지 못하므로 이를 이유로 계속 고용을 거절하는 것은 합리적 이유가 없다(남녀고용평등법 제14조 제6항, 벌칙 제37조 제2항). 이와 마찬가지로 사용자는 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 신고한 근로자와, 직장 내 괴롭힘과 관련하여 피해를 입거나 입었다고 주장하는 근로자에게 해고나 그 밖의 불리한 처우를 하여서는 아니되므로 이를 이유로 계속 고용을 거절하는 것도 합리적 이유가 없다(근로기준법 제76조의3 제6항, 벌칙 제109조 제1항). 더 나아가 사용자가 근로기준법 등을 위반하였음을 근로감독관에게 통고한 것을 이유로 근로자에게 한 사실을 해고나 그 밖에 불리한 처우를 하지 못하므로 이를 이유로 계속 고용을 거절하는 것도 마찬가지이다(근로기준법 제104조, 벌칙 제110조). 이 경우에도 근로자가 통고한 내용이 근로기준법 위반 사실이 확정되지 않더라도 근로자의 입장에서 충분히 위반행위로 의심할 만한 사정이 있고, 사용자를 괴롭힐 목적으로 행하는 의도적·반복적 통보행위가 아닌 한 이를 이유로 계속 고용을 거절하는 것도 합리적 이유가 없다고 보아야 한다.

특히 근로자가 노동조합에 가입 또는 가입하려고 하였거나 노동조합을 조직하려고 하였거나 기타 노동조합의 업무를 위한 정당한 행위를 한 것을 이유로 계속 고용을 거절하는 것은 불이익 및 지배·개입의 부당노동행위(노동조합 및 노동관계조정법 제81조 제1항 제1호, 제4호)에 해당하므로 이는 합리적 이유가 없는 것으로 부당하다.

계속 고용 거절의 합리적 이유에 대한 증명책임은 사용자가 부담한다.⁴⁷⁾ 근로기준법 제23조 제1항에 따라 ‘사용자는 근로자에게 정당한 이유 없이’ 해고 등을 하지 못하므로 해고에 정당한 이유가 있다는 점의 주장·증명책임은 사용자에게 있다.⁴⁸⁾ 따라서 해고제한법리를

47) 대법원 2017. 10. 12. 선고 2015두44493 판결

유추 적용하는 기대권 법리도 마찬가지로 계속 고용 거절의 ‘합리적 이유’의 주장·증명책임도 사용자에게 있다. 사용자가 변경되는 기대권 B그룹은 새로운 사용자가 계속 고용 거부의 합리적 이유를 증명해야 하는데 해당 근로자와 기존에 근로관계를 형성하였던 사용자가 아니기 때문에 해당 근로자의 고용승계를 거부할 만한 합리적 이유를 찾기 어려울 뿐만 아니라 이를 증명하기도 어려울 것으로 보인다. 따라서 채용요건 등(후술하는 ‘요건충족형’인 경우)을 구비하지 못했다는 등의 사정이 없는 한 원칙적으로 고용을 승계하는 것이 타당할 것이다.

기대권 인정기준의 단위는 앞서 살펴보았듯이 몇 가지 예외적인 경우를 제외하고 대체로 사업장 단위가 많은 반면, 합리적 이유의 판단 단위는 개별 근로자를 기준으로 판단해야 한다.

2. 합리적 이유의 유형에 따른 판단기준

계속 고용 거절의 합리적 이유에 대한 판단기준은 기대권의 유형에 따라, 거절의 이유 및 사정에 따라 달라질 수 있고, 이를 엄격하게 분류할 수 없더라도 대체로 유형화하면 아래와 같이 3가지로 나누어 살펴볼 수 있다.

(1) 요건충족형

기대권A그룹은 ‘일정한 요건이 충족’되면 고용이 계속되리라는 기대권인 만큼 이때의 합리적 이유는 일정한 요건의 충족 여부가 될 것이다. 그리고 기대권B그룹인 경우에도 고용을 승계할 대상자나 정규직으로 전환 채용할 대상자를 선정하는 요건을 정하는 경우가 있는데 이 경우에도 그 요건의 충족 여부가 합리적 이유가 된다. 이들을 요

48) 대법원 1992. 8. 14. 선고 91다29811 판결 등

전충족형이라 한다.

이때 ‘일정한 요건’ 자체가 합리성의 통제를 받는지 여부가 문제가 될 수 있다. 요건 설정 자체는 사용자의 고유권한에 속하므로 이러한 요건에 대한 객관성, 합리성 및 적절성에 대한 사법심사는 특별한 경우를 제외하고 자제될 수밖에 없다. 그러나 차별적 요건의 설정 등으로 강행법규에 반하거나, 부당노동행위 등의 불순한 동기로 남용하는 등 현저히 합리성을 결하여 부당하다고 인정되는 경우 요건 자체는 무효라고 보아야 하고, 이러한 요건에 따라 계속 고용을 거부하는 것은 부당하다.

첫째, 구체적인 평가기준 및 절차를 요건으로 정한 경우인데⁴⁹⁾, 명시적 규정이 있는 기대권A그룹이나 고용승계할 대상자나 정규직으로 전환 채용할 대상자를 선정할 요건을 정하는 기대권B그룹이 이에 속할 것이다. 사용자 스스로 평가기준 및 절차를 정하였으므로 이를 준수하여야 그 정당성이 인정된다. 이러한 경우 평가기준의 객관성 및 합리성⁵⁰⁾, 평가방법의 적절성(상대평가 & 절대평가)⁵¹⁾, 평가의 적용상

49) 구체적 기준이 없이 ‘평가결과를 고려하여 인사위원회에서 계속 고용 여부를 결정한다’고 정한 경우에도 이에 속한다.

50) 평가기준의 객관성을 상실하였다고 본 사례: 대법원 2006. 2. 24. 선고 2002다 62432 판결, 대법원 2016. 11. 10. 선고 2014두45765 판결, 서울고등법원 2008. 5. 9. 선고 2007누30057 판결

51) 상대평가는 근로자들 간 비교를 통하여 개별 근로자의 위치를 부여하는 것이므로 개별 근로자의 근무실적 및 근무태도 등을 그대로 고과하는 평가방법이 아니다. 특히 상대평가 결과 하위 순위·등급에 해당하는 근로자를 고용종료시키는 경우는 직무수행능력 및 근무태도 등과 상관없이 일정 비율의 근로자가 언제나 고용종료될 수밖에 없게 된다. 따라서 이러한 경우는 합리적 이유가 있다고 볼 수 없다. 실제 근무평가를 상대평가의 방식으로 하여 전체 피평가자 중 일정비율로 등급을 강제할당(C등급 20%, D등급 10%)하고, 계약갱신 기준이 C등급 이하이거나 D등급인 경우에는 개별 근로자의 근무능력과 근무태도 등에 관계없이 무조건 전체 기간제근로자의 30% 내지 10%가 갱신계약 대상에서 제외한 사안에서 판례는 사회통념상 합리적이라고 볼 수 없다고 판단하였다(서울고등법원 2009. 9. 25. 선고 2009누1183 판결). 기대권과 관련한 사안은 아니나 동일한 취지로 판단한 사례로 대법원 2006. 2. 24. 선고 2002다62432 판결(시용근로자의 본채용 거부)

공정성⁵²⁾, 평가절차의 정당성 및 투명성, 평가결과의 공정성 및 타당성⁵³⁾ 등을 갖추었는지를 판단해야 한다.⁵⁴⁾ 이와 같이 평가기준 및 절차를 요건으로 정하였다면 이의 충족 여부만이 합리적 이유의 유무를 판단하는 유일한 기준이 될 것이며, 그 외의 사정을 개제시킬 수 없다. 다만, 요건충족형이더라도 근로기준법 제24조의 경영상 해고를 할 정도의 긴박한 경영상 필요성이 발생한다면 뒤의 ‘경영상 판단형’에 따라 합리적 이유를 판단해야 할 것이다.

한편 평가기준 및 절차 등을 정하고 있는 평가규정 등은 취업규칙에 해당하므로 이의 적용을 받는 근로자에게 불리하게 변경한 경우에는 취업규칙 불이익 변경의 절차를 거쳐야 한다. 즉 근로자의 집단적 의사결정방법에 의한 동의, 당해 사업장에 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 그 노동조합, 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 없는 경우에는 근로자 과반수의 동의(근로기준법 제94조 제1항 단서)를 받아야 한다. 판례⁵⁵⁾는 근로계약 갱신 여부를 결정하는 평가방식을 절대평가에서 상대평가로 변경한 계약직 운용지침은 기간제근로자에게 불리하게 변경하는 것이므로 기간제근로자 과반수의 동

52) 평가의 적용상 공정성을 상실하였다고 본 사례: 대법원 2011. 4. 14. 선고 2007두1729 판결, 대법원 2015. 1. 15. 선고 2012두18868 판결, 대법원 2016. 11. 10. 선고 2014두45765 판결, 서울고등법원 2009. 11. 13. 선고 2009누9354 판결, 서울고등법원 2009. 11. 20. 선고 2009누11524 판결, 서울고등법원 2009. 11. 26. 선고 2009누11531 판결 등. 기대권과 관련한 사안은 아니나 동일한 취지로 판단한 사례로 대법원 2006. 2. 24. 선고 2002다62432 판결(시용근로자의 본채용 거부), 서울행정법원 2004. 9. 17. 선고 2003구합23769 판결(징계사건)

53) 평가결과의 공정성 및 타당성을 상실하였다고 본 사례: 대법원 2011. 4. 14. 선고 2007두1729 판결, 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009두2665 판결, 서울고등법원 2009. 11. 13. 선고 2009누9354 판결. 기대권과 관련한 사안은 아니라 동일한 취지로 판단한 사례로 대법원 2012. 5. 24. 선고 2011두11310 판결(경영상 해고 시 대상자 선정기준)

54) 구체적인 내용은 강선희, “인사평가와 사법심사Ⅰ”(『노동법포럼』 제23호, 노동법이론실무학회, 2018. 2.)과 “인사평가와 사법심사Ⅱ”(『노동법포럼』 제24호, 노동법이론실무학회, 2018. 7.) 참조

55) 서울고등법원 2009. 9. 25. 선고 2009누1183 판결

의를 얻어야 하나 이를 얻지 못하여 변경된 계약직 운용지침은 기간제근로자에게 적용되지 않는다고 판단한 바 있다.

둘째, 요건을 첫 번째와 같이 구체적 기준 없이 추상적으로 설정하더라도 요건을 특정하였다고 볼 만한 경우이다. 예컨대 계속 고용요건을 ‘특별히 건강상의 문제가 없다면’, ‘업무수행능력이 현저히 부족하지 않다면’ 등으로 특정되어 있는 경우에는 특정된 요건의 충족여부만을 합리적 이유로 판단하여야 하고, 사용자는 근로자가 특정된 요건을 충족시키지 못하였다는 사실을 증명하여야 한다.

(2) 종합판단형

계속 고용의 요건이나 승계 및 채용의 대상자 선정 기준이 위 요건충족형과 같이 구체적인 평가기준 및 절차를 정하거나 특정되었다고 볼 만한 경우가 아니라 개방형으로 ‘특별한 사정이 없다면’ 또는 ‘특별히 문제가 없다면’이라고 규정하거나 그와 같은 관행이 형성되어 있는 경우이다. 이때 ‘특별한 사정’ 등은 계속 고용을 거절할 ‘합리적 이유’이고⁵⁶⁾, 여기에는 ‘근무태도나 근무성적 등이 특히 불량하지 않다면’이라는 형태로 개방한 경우도 포함된다. 이러한 경우 제반 사정을 종합하여 볼 때 계속 고용 거절에 사회통념상 상당하다고 인정되는 합리적 이유가 있어야 하고, 이러한 측면에서 이러한 유형을 종합판단형이라 명명한다. 이와 같은 종합판단형은 앞서 언급한 해고의 기준인 ‘정당한 이유’보다 완화된 기준의 ‘합리적 이유’가 적용된다. 요건충족형의 합리적 이유는 오로지 요건의 충족 여부에 있으므로 이와 같은 완화된 기준이 적용될 여지가 없다.

종합판단형의 합리적 이유는 주로 개별 근로자의 근로관계를 둘러

56) 실무에서 도급업체와 새로운 용역업체 간에 고용승계조항을 약정할 경우 “‘특별한 사정이 없는 한’ 현재 근무하고 있는 종업원을 고용승계 및 용역계약기간 중 고용 유지하여야 한다.”라고 정하는 경우가 상당수 있다(각주26 용역계약서의 청소용역 시방서 참조).

싸고 발생하여 그에 귀속될 만한 사유를 말한다.

판례⁵⁷⁾는 근로계약 갱신에 대한 정당한 기대권을 인정하는 취지는 기간제 근로계약의 남용을 방지함으로써 기간제근로자의 근로조건 보호를 강화하려는 데에 있음을 강조하면서 “근로자에게 이미 형성된 갱신에 대한 정당한 기대권이 있음에도 불구하고 사용자가 이를 배제하고 근로계약의 갱신을 거절한 데에 합리적 이유가 있는지가 문제될 때에는 사용자의 사업 목적과 성격, 사업장 여건, 근로자의 지위 및 담당 직무의 내용, 근로계약 체결 경위, 근로계약의 갱신에 관한 요건이나 절차의 설정 여부와 그 운용 실태, 근로자에게 책임 있는 사유가 있는지 여부 등 당해 근로관계를 둘러싼 여러 사정을 종합하여 갱신 거부의 사유와 그 절차가 사회통념에 비추어 볼 때 객관적이고 합리적이며 공정한지를 기준으로 판단”해야 한다고 판시하였다.⁵⁸⁾

한편 개별 근로자에게 귀속될 만한 경영상 또는 업무상 사정도 이에 속하는지 아니면 경영상 판단형에 포함하여 판단하여야 하는지 문제시될 수 있다.

근로자가 담당하던 업무가 소멸하거나 한시적 사업 또는 업무를 수행하기 위해 기간제 근로계약(사업의 완료 또는 특정한 업무의 완성에 필요한 기간을 정한 근로계약)을 체결하였으나 그 사업이나 업무가 종료되거나 폐지된 경우는 기대권을 인정하기 어려울 것이므로 합리적 이유에서 검토될 가능성이 그리 많지 않을 것으로 보인다. 그러나 경우에 따라서 기대권이 인정될 여지도 있는데, 예컨대 1년 단

57) 대법원 2017. 10. 12. 선고 2015두44493 판결. 이에 대한 평석으로 강선희, “근로계약 갱신 거절의 합리적 이유 판단기준 및 이의 증명책임 등 - 대법원 2017. 10. 12. 선고 2015두44493 판결-”, 월간 「노동리뷰」 2017년 12월호, 한국노동연구원, 99~102면 참조

58) 판단요소별 구체적 판단기준 및 사례분석에 대해서는 김홍영, “기간제 근로자의 고용 보장 법리-갱신기대권 법리의 검토”, 「법학논총」 제39권 제2호, 한양대학교 법학연구소, 2022, 233~239면; 도재형·노상현·최지윤, 「갱신기대권(정규직 전환기대권) 관련 판단기준에 대한 연구」(중앙노동위원회 학술연구용역사업), 중앙노동위원회, 2018, 88~129면 참조

위로 근로계약을 체결하면서 “근로계약기간은 1년(2020. 6. 1.~2021. 5. 31.)으로 하되, A사업 종료예정인 2023. 12. 31.까지 특별한 사정이 없다면 근로계약을 갱신할 수 있다.”라고 근로계약을 체결하였으나 2022. 4. A사업 공정의 변경으로 해당 근로자가 담당하던 업무가 폐지되어 2022. 5. 31. 갱신이 거절된 경우이다. 이와 같은 경우는 기대권은 인정되나 근로자의 담당 업무의 소멸로 갱신 거절의 합리적 이유가 있다고 볼 수 있다. 이러한 경우를 뒤의 경영상 판단형으로 볼 수도 있을 것이나 개별 근로자에게 귀속되는 경영상 또는 업무상 사정으로 보아 종합판단형의 합리적 이유로 판단하는 것이 타당하다. 계속 고용 거절의 이유가 경영상 또는 업무상 사정으로 발생했으나 개별 근로자에게 귀속되어 대상자 선정을 고려할 필요가 없는 경우이다. 위의 판단요소 중 ‘사용자의 사업 목적과 성격, 사업장 여건, 근로자의 지위 및 담당 직무의 내용, 근로계약 체결 경위’에 포함하여 판단할 수 있다.

(3) 경영상 판단형

이 유형은 경영상 및 업무상 사정으로 계속 고용 기대권이 인정되는 다수의 대상자 중 선택적으로 거부하거나 대량 거부하는 경우에 합리적 이유를 판단하는 것으로, 편의상 경영상 판단형으로 약칭한다. 경영상 및 업무상 사정이더라도 대상자를 선정할 필요가 없다거나 대량 거부하는 경우가 아니라면 종합판단형으로 고려되어야 할 것이다. 기대권③의 경우 정년에 도달하는 근로자가 순차적으로 발생하기 때문에 선택적으로 거부할 상황이 많지 않을 것이나 정년 퇴직일을 특정 날짜(6월 말, 12월 말 또는 분기말 등)로 정하여 선택적으로 거부해야 할 경우에는 이 유형에서 판단하는 것이 타당하다.

이와 관련하여 판례⁵⁹⁾는 “특히 사용자가 갱신에 대한 정당한 기대

59) 대법원 2017. 10. 12. 선고 2015두44493 판결

권을 보유한 기간제근로자들에 대하여 사전 동의 절차를 거치거나 가점 부여 등의 구체적인 기준도 마련하지 않은 채 재계약 절차가 아닌 신규채용절차를 통하여 선발되어야만 계약 갱신을 해주겠다고 주장하면서 대규모로 갱신 거절을 한 경우, 이는 근로자의 갱신에 대한 정당한 기대권을 전면적으로 배제하는 것이므로, 사용자로서 그와 같은 조치를 취하지 않으면 안 될 경영상 또는 운영상의 필요가 있는지, 그에 관한 근거 규정이 있는지, 이를 회피하거나 갱신 거절의 범위를 최소화하기 위한 노력을 하였는지, 그 대상자를 합리적이고 공정한 기준에 따라 선정하기 위한 절차를 밟았는지, 그 과정에서 차별적 대우가 있었는지 여부 등을 종합적으로 살펴보고 그 주장의 당부를 판단하여야 한다.”라고 판시하였다. 위 판결 내용 중 ‘차별적 대우가 있었는지 여부’는 ‘그 대상자를 합리적이고 공정한 기준에 따라 선정하기 위한 절차를 밟았는지 여부’를 판단하는 요소로 보인다. 앞서 언급하였듯이 차별금지법을 위반하여 대상자를 선정하는 경우에는 합리적이고 공정한 기준이라 볼 수 없기 때문이다.

위 판시내용은 근로기준법 제24조의 ‘경영상 이유에 의한 해고’의 요건과 맥을 같이 하는 것으로 보이는데, 앞서 언급한 계속 고용 거절의 합리적 이유는 주로 근로자 측의 사정에 의해 발생하고, 이는 주로 사용자 측의 사정에 의해 발생하는 것으로 볼 수 있기 때문이다. 그러나 엄밀하게 말하면 근로기준법 제24조를 유추 적용하는 것이 아니라 원용하는 것이므로 법관은 적용할 사안, 각 요소의 구비 여부 등에 대한 판단은 근로기준법 제24조의 해석보다 자유롭다.

예컨대 도급업체가 예산삭감 등을 이유로 종전 용역인원을 줄여 위탁할 경우 새로운 용역업체가 줄어든 인원만큼 승계를 거부할 경우(기대권④), 긴박한 경영상의 이유로 기간제근로자의 갱신이나 정규직의 전환을 50% 거부할 경우(기대권①·②) 등이다.

V. 맺는 글

이상에서 2024년 현재까지 판례 법리로 형성된 계속 고용 기대권, 즉 갱신기대권, 정규직 전환 기대권, 정년 후 재고용 기대권, 고용승계기대권, 정규직 전환 채용 기대권 법리를 검토하였다. 그리고 이를 기대권의 인정기준과 판단요소, 계속 고용 거절의 합리적 이유의 유형화와 이에 따른 판단기준을 중심으로 살펴보았다. 합리적 이유가 없는 경우 기대권별로 법적 효과에 차이가 있는데, 동일한 사용자를 대상으로 하는 기대권A그룹은 큰 무리가 없을 것이나 사용자가 변경되는 기대권B그룹은 달리 판단해야 한다. 용역업체 변경 시 적용되는 고용승계기대권과 관련된 법적 효과⁶⁰⁾를 제외한 외주화(outsourcing), 직영(insourcing)의 경우에 적용되는 기대권과 정규직 전환 채용 기대권과 관련된 법적 효과는 전적(轉籍) 시의 법적 효과를 원용하면 될 것이다.

기간제근로자의 고용종료에 대한 보호장치가 없을 때 그 기능을 담당하는 판례 법리로 출발한 사실상 무기계약 법리와 갱신기대권 법리는 위에서 보는 바와 같이 그 외연을 확장하고 있고, 판단기준 역시 진화를 거듭하고 있다. 계속 고용 기대권 법리는 유추의 방식을 통한 법관의 법형성으로 근로관계 종료에 대한 예외로서 탄생한 것이기 때문에 지나치게 확대할 수 없다는 태생적 한계가 있을 수 있다. 그러나 법리상 원칙과 예외가 바뀔 수는 없더라도 법원이 그간 근로자의 보호필요성에 따라 기대권 인정의 폭을 달리하면서 사용자의 부담한 고용종료부터 상당한 보호기능을 수행하였듯이 향후로도 이의 확대·적용을 기대해 본다. 왜냐하면 근로기준법 제23조 제1항의 해고제한법리를 유추 적용할 만한 노동현실이 여전히 상당수 존재하기 때문이다.

60) 강선희, “위탁 등 아웃소싱과 노동법적 쟁점-기간제근로자를 중심으로-” 참조

174 근계속 고용 기대권 - 5가지 기대권 법리-

주제어: 계속 고용 기대권, 갱신기대권, 정규직 전환 기대권, 정년 후 재고용 기대권, 고용승계기대권, 정규직 전환 채용 기대권, 계속 고용 거절의 합리적 이유

【참고문헌】

- 강선희, “위탁 등 아웃소싱과 노동법적 쟁점-기간제근로자를 중심으로 -”, 「노동법포럼」 제38호, 노동법이론실무학회, 2023.
- 강선희, “정년 후 재고용 기대권 - 대상판결①: 대법원 2023. 6. 1. 선고 2018다275925 판결, 대상판결②: 대법원 2023. 6. 29. 선고 2018두62492 판결 -”, 「노동리뷰」 2023년 8월호, 한국노동연구원, 2023.
- 강선희, “기간제근로자의 고용종료를 보호하기 위한 판례 법리”, 「노동법학」 제87호, 한국노동법학회, 2023.
- 김홍영, “기간제근로자의 고용 보장 법리-갱신기대권 법리의 검토”, 「법학논총」 제39권 제2호, 한양대학교 법학연구소, 2022.
- 도재형 · 노상현 · 최지윤, 「갱신기대권(정규직 전환기대권) 관련 판단 기준에 대한 연구」(중앙노동위원회 학술연구용역사업), 중앙노동위원회, 2018.
- 오윤식, “기간제 근로자의 근로계약 갱신기대권 법리”, 「민주법학」 제50호, 민주주의법학연구회, 2012.
- 이시윤, 「신민사소송법」 제10판, 박영사, 2016.
- 지원림, 「민법강의」 제9판, 홍문사, 2011.

[Abstract]

Expectant Right to Continued Employment

- 5 Legal Principles of Expectant Right -

Kang Sunbee

This article reviewed the legal principles of the right to expect continued employment, which have been formed by the case law so far in 2024, that is, the right to expect employment renewal, the right to expect conversion to regular employment, the right to expect re-employment after retirement, the right to expect employment succession, and the right to expect to be converted to regular employment.

First, this article examined the concept and types of the rights to expect continued employment. And then, it was reviewed by breaking down into three categories : the criteria for judging and judgment elements of expectant right, and ‘special circumstances’ that could deny the formation of expectant rights. Finally, after examining the general contents of ‘reasonable grounds’ for refusing continued employment, I have categorized the reasonable grounds and reviewed the criteria according to type.

When there are not reasonable grounds, there will happen differences in the legal effects for each expectant right. The expectant right with the same employer(group A) will not face severe difficulties, but the expectant right of group B which experience changes of the employer should be judged differently. Excluding the legal effects related to the right to expectation of the employment succession that applied when outsourcing

* Lecturer, Korea University.

companies are changes, the legal effects related to the expectant right which applied in the case of outsourcing or insourcing and the expectation rights to be converted to regular employment can be applied to the legal effects in transferring between companies as well.

When there is no protection against the termination of employment of fixed-term employees, the right to expect renewal, which started as a precedent legal principle in charge of its function, is expanding its scope, as seen above, and the criteria for judgment are also evolving. Since the right to expect continued employment was created as an exception to the termination of an employment relationship due to Law-Forming action (*Rechtsfortbildung*) by judges through the method of analogy, there is a limitation that it cannot be interpreted too broadly.

However, even though the principles and exceptions cannot be changed, the court is expected to expand and apply these in the future, just as it has performed a significant protection roles from the unfair termination of employment by employers while varying the scope of recognition of expectant rights according to the needs for protection of employees. This is because there are still many labor realities that can apply to legal principles of restriction of dismissal under Article 23 (1) of the Labor Standards Act.

Key word: Expectant Right to Continued Employment, Renewal Expectant Right, Right to Expect Conversion to Regular Employment, Right to Expect Re-employment after Retirement, Right to Expect Employment Succession, Right to Expect to be Converted to Regular Employment, Reasonable Grounds for Refusing Continued Employment